4　特許権〔patent right〕

(1) 特許権とその保護の対象である発明

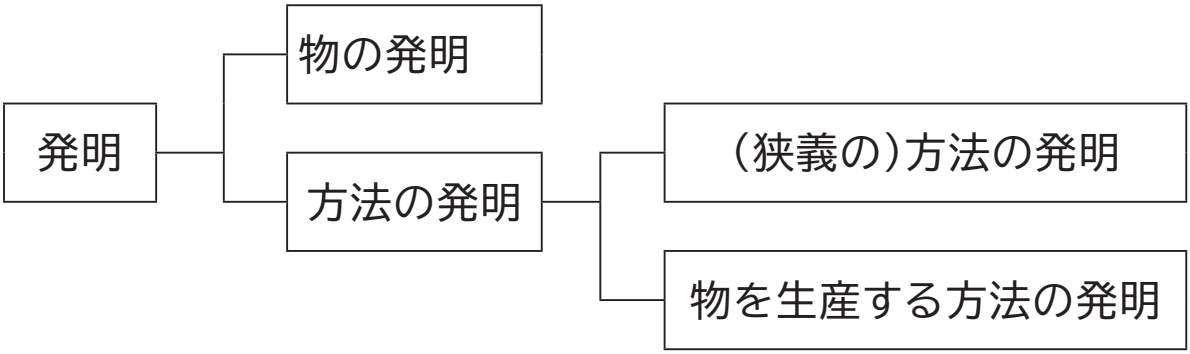
特許権は、特許を受けた発明を、業として（事業として）独占排他的に実施する権利である。特許権者は、業として、特許権設定の登録を受けた発明（特許発明）を実施する権利を専有する（特許法68条）。

発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものである（特許法2条1項）。「自然法則を利用した」ものであることを要するため、自然法則以外の法則（例えば経済法則）、人為的取決め（例えばゲームのルール自体）のように自然法則と無関係の着想は発明とならない。また、高度でない創作は、特許権ではなく実用新案権の保護対象となり得るにとどまる。また、「創作」であるから人為的なものでなければならず、この点で発明は天然物や自然現象の単なる発見と異なる。

発明は、物の発明および方法の発明に分けることができ、方法の発明はさらに、（狭義の）方法の発明と物を生産する方法の発明に分けられる（特許法2条3項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（発明の分類）



（注）物の発明には、プログラム等も含まれる（特許法2条3項1号4項）。

特許権を取得するには、発明が産業上の利用可能性、新規性、進歩性（特許法29条）その他の登録要件を充たす必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ポイント整理

《特許要件》

特許権が認められるためには、特許を受けようとする発明について、以下の要件（特許要件）を充たしていること、および不特許事由（特許法32条）に該当しないことが必要である。

産業上の利用可能性 （特許法29条1項柱書）	発明が産業上利用し得るものであること。産業には、工業だけでなく農林水産業、鉱業、商業のほかサービス業も含まれる。
新規性 （特許法29条1項1～3号）	発明がいまだ社会に知られていないものであること。新規性の有無は、具体的には新規性喪失事由（①狭義の公知、②公用、③刊行物記載等）の有無により判断される。
進歩性 （特許法29条2項）	発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、特許出願時の技術常識に基づいて容易に発明をすることができないこと。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2) 特許を受ける権利〔right to obtain patent〕

特許を受ける権利は、発明の完成と同時に発明者に原始的に帰属する。発明者は自然人に限られ、法人は発明者になり得ない。ただし、法人も特許を受ける権利の承継人にはなり得る。特許出願は、特許を受ける権利を有する発明者またはその承継人のみがすることができる。

特許を受ける権利を有しない者による出願を一般に冒認(ぼうにん)出願という。冒認出願は拒絶理由となり(特許法49条7号)、仮に誤って登録された場合は、特許登録の無効理由となる(特許法123条1項6号)。

特許を受ける権利は、原則として、特許出願をする前に他人に移転することができる(特許法33条1項)。特許を受ける権利は、特許出願前に移転する場合と、特許出願後に移転する場合などでは、効力発生要件や対抗要件が異なるため注意が必要である(特許法34条)。

特許を受ける権利は質権の目的とすることができないが(特許法33条2項)、特許を受ける権利に譲渡担保を設定することはできる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（特許を受ける権利の移転）

		効力発生要件	対抗要件	その他
特許出願前（特定承継・一般承継共通）		●承継事由（売買契約等）の発生 ただし、契約等に効力発生につき特段の定めがある場合にはその定めに従う	●特許出願（特許法34条1項）	－
特許出願後（設定登録前）	特定承継	●承継事由（売買契約等）の発生 ＋ ●特許庁長官への届出 （特許法34条4項）	－	－
	一般承継	●承継事由（相続等）の発生	－	●特許庁長官への届出 （特許法34条5項）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q)特許を受ける権利について、特許出願前に移転する場合と、特許出願後に移転する場合とで、その効力発生要件や対抗要件はどのように異なるか。

A)特許出願前に特許を受ける権利を移転する場合、権利移転の効力は承継事由の発生とともに生ずる。例えば、売買契約に基づいて特許を受ける権利を移転する場合であれば、効力発生について特段の定めがあるときを除き、売買契約の締結自体が効力発生要件である。

　そして、特許出願前における特許を受ける権利の移転を第三者に対抗するための要件は、特許出願である(特許法34条1項)。つまり、特許を受ける権利の承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。

　これに対し、特許出願後に特許を受ける権利を移転する場合には、さらに、移転の原因に応じて効力発生要件が異なる。移転の原因は、会社の合併・相続などの一般承継と、譲渡(売買)・贈与などの特定承継に分けられる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

特許を受ける権利の特定承継は、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない（特許法34条4項）。つまり、この場合の効力発生要件は、特許庁長官への届出である。一方、特許を受ける権利の一般承継では、その承継事由の発生と同時に権利移転の効力が発生するが、承継人は遅滞なくその旨を特許庁長官に届け出なければならない（特許法34条5項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q)特許を受ける権利について、特許を受ける前に、当該特許を受ける権利にかかる発明の実施を他人に許諾することはできるか。

A)特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、一定の範囲内において、仮専用実施権を設定し(特許法34条の2)、または他人に仮通常実施権を許諾することができる(特許法34条の3)。

仮専用実施権の設定については、登録しなければその効力を生じない(特許法34条の4第1項)。

仮専用実施権にかかる特許出願について特許権の設定の登録があったときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなされる(特許法34条の2第2項)。仮通常実施権についても同様の定めがある(特許法34条の3第2項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3) 職務発明〔employee invention〕

職務発明とは、従業者等（従業者、法人の役員、国家公務員または地方公務員）が行った発明であって、その性質上、その従業者等が属する使用者等（使用者、法人、国または地方公共団体）の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った研究開発などの行為がその従業者等の現在または過去の職務に属するものをいう（特許法35条1項）。企業の従業者は、企業の設備投資等を背景に、職務として研究・開発業務に携わり発明を創作することが多く、特許法の職務発明の規定により使用者等と従業者等との利害が調整されている。

職務発明については、原則として、発明をした従業者等が特許を受ける権利を有する。従業者等が職務発明につき特許権を取得した場合、使用者等には、特許法により、その特許権について通常実施権が認められる（特許法35条1項）（通常実施権については、本項(9)参照）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

この特許法の規定に対し、職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めておくことができ、これによって、当該発明をした従業者等ではなく、使用者等にその特許を受ける権利を発生時から原始的に帰属させることもできる（予約承継、特許法35条3項）。

そして、従業者等が、契約、勤務規則等の定めにより使用者等に職務発明にかかる特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、または使用者等のため専用実施権を設定等したときは、従業者等は使用者等から「相当の金銭その他の経済上の利益」（相当の利益）を受ける権利を有する（特許法35条4項）。相当の利益には、金銭以外の経済上の利益（昇進など）も含まれる。これは、従業者等が権利の対価を受け取れるとすることにより発明を奨励するためである。

特許法35条6項に基づいて、経済産業大臣は、研究を奨励するため、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業員等との間で行われる協議の状況等について、指針を公表している（特許法第35条第6項の指針（ガイドライン））。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　職務発明と業務発明

会社等の従業者等がその研究設備等を利用して職務として研究開発した発明は職務発明と呼ばれる。職務発明については、契約や勤務規則で会社等の使用者に特許を受ける権利を与えるよう定められていることがある。

一方、研究開発に従事していない従業者が職務と無関係に会社業務に属する発明をした場合、この発明は業務発明と呼ばれる。業務発明については、会社は全く投資をしておらず、従業者の自発性の発揮による成果であるため、あらかじめ契約等で会社が権利を譲り受ける旨の定めがなされても、このような定めは特許法により無効である（特許法35条2項）。

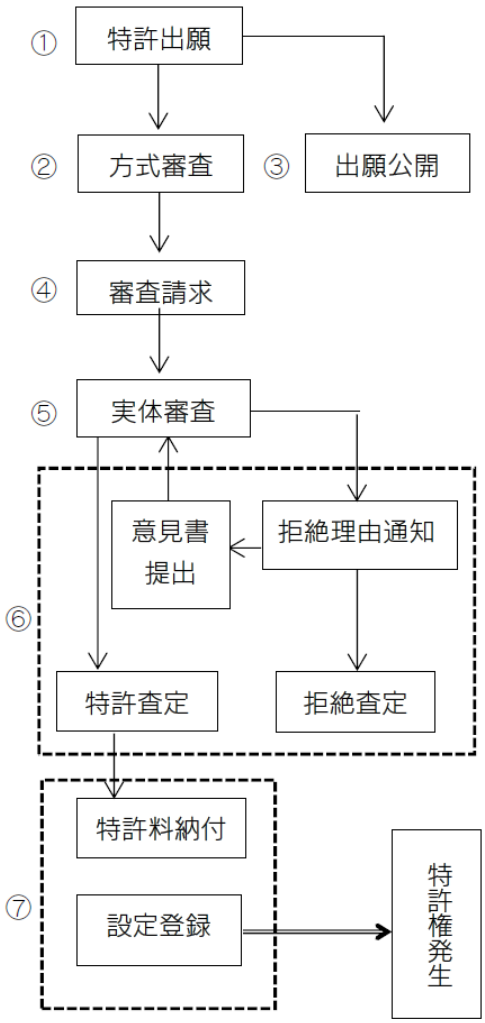
（4）特許権取得手続

特許権は、特許を受けようとする発明を特許庁長官に出願し、審査官による審査を経て特許査定を得て、所定の期間内に特許料を納付した後、特許登録原簿に登録されることによって成立する。その手続の流れは次の図の通りである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（特許権取得手続の流れ）

図中の引用条文はすべて特許法上のものである。



①特許を受けようとする者は、所定の書類を提出して、特許庁長官に対して発明を出願しなければならない（36条）。

②方式審査は、なされた出願の形式面を審査するものである。方式に不備がある場合は、補正命令等がなされ（17条）、補正がない場合などには出願が却下される（18条）。

③原則として出願の日から1年6か月経過すると、特許出願の内容が特許公報に掲載され公開される（64条）。

④出願された発明に対する実体審査は、特許出願後、一定の期間内に出願審査の請求をしたものについてのみ行われる（48条の2）。

⑤発明が新規性や進歩性、所定の記載要件などの特許要件を具備しているかなど、出願内容の実体について審査される。

⑥拒絶理由が発見されない場合には、特許をすべき査定（特許査定）がなされる（51条）。拒絶理由があれば、それが出願人に通知され、意見書提出の機会が与えられるが（50条）、それでも拒絶理由が解消されなければ拒絶査定がなされる（49条）。拒絶査定に対しては、これを不服とする審判の請求が可能である。

⑦特許査定がなされると特許査定謄本が送達され、所定の期間内に特許料を納付すれば特許権の設定登録がなされる（66条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(5) 先願〔prior application〕主義

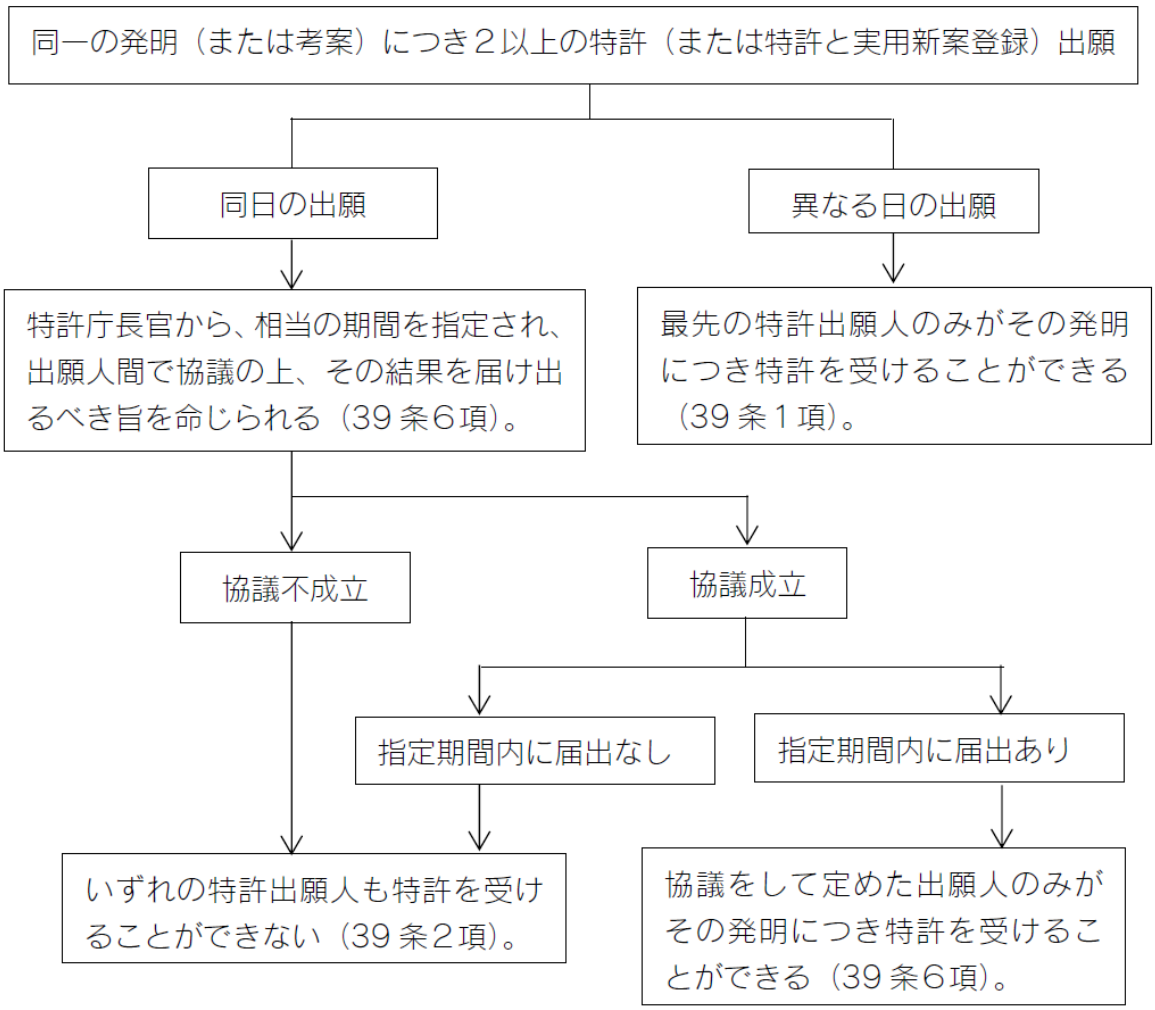
特許権は排他的な権利であり、同一の発明について重複して特許権が付与されることはない。例えば、複数の者が別個独立に同一の発明を完成した場合には、各人に特許を受ける権利が発生するが、それらの者のうち最先の出願人のみがその発明につき特許を受けられる（特許法39条）。これを先願主義という。

なお、実用新案権の対象である考案は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である点では発明と同じである。そのため、先願主義に関する上記の処理は複数の特許出願の間だけでなく、特許出願と実用新案登録出願との間にも妥当する（特許法39条3項4項、実用新案法7条3項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（先願主義）

図中の引用条文はすべて特許法上のものである。



© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）「出願公開」とはどのような制度か、また出願公開によっていかなる効果が認められるか。

A）出願公開制度とは、特許出願の日から1年6か月を経過したときに特許出願の内容を特許公報（出願公開公報）に掲載して公開する制度である（特許法64条）。出願された発明に関する情報の公開が遅くなると、それだけ他者による重複出願や重複研究投資の可能性が高まるため、登録前であっても早期に、出願された発明に関する情報を公開することによって、これらを可能な限り防止することがこの制度の目的である。ただし、1年6か月を経過する前に登録され、特許掲載公報の発行されたものは除かれる。

　また、出願人は、特許出願の日から1年6か月を経過する前であっても、原則として、特許庁長官に対して出願公開の請求をすることができる（特許法64条の2第1項）。この出願公開請求は、取り下げることができない（特許法64条の2第2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

出願公開後は発明が一般に広く知られることになり、特許権の設定登録前に第三者が業として当該出願にかかる発明を実施するおそれがある。そこで出願公開による出願人の損失てん補を目的として、一定額の補償金を請求する権利（補償金請求権）が出願人に認められている（特許法65条）。

具体的には、出願公開された発明について特許権の設定登録がなされる前に当該発明を業として実施している者に対し、特許出願人は、出願にかかる発明内容を記載した書面を提示して警告する。特許出願人は、特許権の設定登録がなされた後に、その者に対し補償金の支払いを請求することができる。ただし、出願公開された発明であることを知って実施する者に対しては、警告をしなくても補償金請求権を行使できる。なお、出願公開後、特許出願の放棄、取下げ、却下、拒絶査定・無効審決が確定したとき、特許料不納により特許権が初めから存在しなかったものとみなされたときには、補償金請求権は初めから生じなかったものとみなされる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）発明が特許要件等を具備しているか否かの審査（実体審査）は、特許出願がなされたすべての発明について行われるか。

A）実体についての審査は、出願にかかる発明が特許要件を充足しているかどうかについてなされる審査である。

　実体審査については、特許出願がなされた後、一定期間内に特許庁長官に対して出願審査の請求をした出願についてのみ審査がなされる（出願審査請求制度、特許法48条の2）。

　出願審査請求制度の趣旨は、真に権利化を望む出願に対してのみ実体審査をすることで審査の迅速化を図ることにある。

　特許出願人だけでなく第三者であっても、出願審査請求書を提出し、審査手数料を納付して出願審査の請求をすることができる。それは、当該発明に関係のある第三者も、出願について特許権が成立するか否かにつき利害関係を有するからである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、出願審査の請求は、特許出願があった日から3年以内にしなければならない。出願から3年以上経過しても審査請求されない出願は、原則として取り下げられたものとみなされる（特許法48条の3第4項）。ただし、その期間内に特許出願について出願審査の請求をすることができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から2か月以内かつ期間の経過後1年以内に限り、出願審査の請求をすることができる（特許法48条の3第5項）。

COLUMN　補償金請求権

発明について出願公開がなされた後は発明が一般に広く知られることになる。そのため、特許権の設定登録前に第三者が業として当該出願にかかる発明を実施するおそれがある。そこで、出願公開による出願人の損失てん補を目的として、出願人には当該発明を実施した者に対して一定額の補償金を請求する権利（補償金請求権）が認められている（特許法65条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(6) 特許権の効力

特許権は、設定登録により発生する(特許法66条1項)。

特許権者は、業として特許発明を独占排他的に実施することができる(特許法68条)。特許発明の実施の内容は、発明の形態ごとに定義されている(特許法2条3項)。

発明の形態	実　施　の　意　義
物の発明	その物の生産、使用、譲渡等(譲渡および貸渡し、インターネット等を通じた提供を含む)、輸出もしくは輸入または譲渡等の申出(展示を含む)をする行為
方法の発明	その方法を使用する行為
物を生産する方法の発明	①その方法を使用する行為 ②その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為

特許権の存続期間は、原則として、登録日から始まり出願日から20年で終了する(特許法67条1項)。これは、発明を公衆に公開する代償として、出願日から、原則として20年間に限って独占排他権を付与し、権利満了後は、公衆に広く利用させることを認めたものである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

なお、特許出願の日から5年を経過した日または出願審査の請求があった日から3年を経過した日のいずれか遅い日以後に特許権の設定の登録があった場合に、特許権の存続期間の延長ができる制度（延長登録制度）が設けられている（特許法67条2項）。

（7）特許発明の技術的範囲

特許権は、特許発明に独占排他的効力を付与するものであるが、特許発明は技術的思想の創作（発明）であって、それ自体は観念的なものである。そのため、その技術的範囲を一義的に決定することは一般に困難であり、特許侵害係争等においては特許発明の技術的範囲が争点となることが最も多い。特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない（特許法70条1項）。特許請求の範囲とは、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認められる事項のすべてを簡潔に記載した部分のことをいい、1つの特許請求の範囲には複数の請求項を記載することができる。この特許請求の範囲に記載される請求項のことをクレーム（claim）とも呼ぶ。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　均等論

特許発明の技術的範囲の解釈を争点とする特許係争は多く、クレームの記述・解釈は特許実務において最重要事項である。クレームは、原則として文言通りに解釈されるが、あまりにも文言通りに技術的範囲を解釈すると、特許権者の保護に欠ける場合がある。そこで、特許発明と均等と認められるものを技術的範囲に含めるとする均等論という理論が唱えられている。アメリカでは1980年代からクレームの解釈について多数の判決が出されており、わが国においても議論されてきたが、最高裁判決の中には均等論適用の要件を判示した上で、均等論の適用を肯定したものがある（最判平10・2・24無限摺動用ボールスプライン軸受事件）。その後の均等論適用の判決としては、ペン型注射器事件（大阪地裁平11・5・27）がある。しかし、一方では均等論適用の要件は従前の判例を踏襲しつつ、結果としては均等論を適用しなかった事例として、徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件（東京地裁平11・1・28）もある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(8) 共同発明・特許権の共有

近年、技術の高度化、研究開発費増大等の理由により複数の企業で共同開発契約を結び、研究・開発を行う例が増えているが、実務上、特許法において共同発明がどのように取り扱われるかは重要な問題である。

共同発明とは、2人以上の者が実質的に協力をして完成した発明のことをいい、創作活動そのものに関与しなかった者は共同発明者とはなり得ない。共同発明者となり得ない者としては、①部下の研究者に対して一般的管理をした者、例えば、具体的着想を示さずに単に通常のテーマを与えた者や発明の過程において単に一般的な助言・指導を与えた者(単なる管理者)、②研究者の指示に従い、単にデータをまとめた者または実験を行った者(単なる補助者)、③発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えることにより、発明の完成を援助した者(単なる後援者・委託者)等がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

共同発明の場合、特許を受ける権利は共同発明者全員が共有する。特許出願をするときは、共有者全員で出願をしなければならない（特許法38条）。特許権が設定された場合には、その特許権は特許を受ける権利の共有者の共有となる。また、特許権が共有にかかる場合は、持分権の譲渡、実施権の設定等には、他の共有者の同意が必要であるが、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得なくても自ら特許発明を実施することができる（特許法73条）。

（9）実施権

ア）実施権とは

特許権者は、自己の特許発明を自ら実施するだけでなく、他者に実施権を設定（許諾）することによって実施料を徴収し、発明への投下資本を回収することもできる。

実施権の主な態様には、専用実施権と通常実施権がある。

実施権の中には、一定の要件を充たせば法律上当然に認められるもの（法定実施権）もあるが、特許権者と実施権者との間の設定契約（実施許諾契約）によって発生するのが通常である。一般に、技術提携・技術導入などが行われる場合、この実施許諾契約が締結される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（実施権の主な態様）

表中の引用条文はすべて特許法上のものである。

	専用実施権	通常実施権	
意義	設定行為で定めた範囲内において、業として特許発明を独占的に実施することができる権利（77条2項）	設定行為等で定められた範囲内において、業として特許発明を実施する権利（78条2項）	
		許諾通常実施権	法定実施権
		特許権者が、その特許権について他人に許諾した通常実施権（78条1項参照） いわゆる独占的通常実施権も許諾通常実施権の一種である	公益上の必要から、特許権者（または専用実施権者）による許諾の有無にかかわらず、法律上当然に発生する通常実施権
効力発生要件	専用実施権設定契約の締結 ＋ 専用実施権の設定登録（98条1項）	実施許諾契約の締結 ただし、契約等に効力発生につき特段の定めがある場合にはその定めに従う	各法定実施権につき特許法の規定する要件を具備すること
同一範囲で複数の者に実施権の設定（許諾）が可能か	不可	可能	可能
同一範囲で特許権者が実施可能か	不可	可能	可能

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

なお、通常実施権は、その発生後にその特許権・専用実施権またはその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力が認められる（当然対抗制度、特許法99条）。したがって、特許権者との間の実施権許諾契約により通常実施権の許諾を得た通常実施権者は、その後特許権を譲り受けた者や特許権者から専用実施権の設定を受けた者から、差止請求や損害賠償請求を受けたとしても、これらの者に対し、通常実施権を対抗することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　法定実施権

特許権についての法定実施権は、職務発明についての通常実施権（特許法35条1項）、先使用者に認められる先使用権（特許法79条）のほかに、無効審判の請求登録前の実施による通常実施権（特許法80条1項。いわゆる中用権）、再審により回復した特許権の効力の制限としての通常実施権（特許法176条。いわゆる後用権）などがある。

中用権は、例えば、Aが発明甲について特許を受け、発明甲を実施して事業を行っていたが、後にAの特許が無効とされた場合において、当該特許を無効とする審判の請求の登録前に、Aが無効原因を知らないときに、Aに認められる通常実施権である。

後用権は、例えば、発明乙についての特許がいったん無効とされたが再審により回復した場合において、当該特許を無効とする審決の確定から再審の請求の登録までの間に、再審理由があることを知らずに、Bが無効審決を信じて日本国内において発明乙を実施して事業を行っているときに、Bに認められる通常実施権である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）専用実施権、通常実施権、独占的通常実施権はどのような点が異なるのか。

A）権利発生の面からいえば、専用実施権は特許庁に登録をすることでその権利が発生するのに対し、通常実施権・独占的通常実施権は特許庁に設定登録を行わなくても、契約を締結するだけでその権利が発生するという違いがある。

　また、権利の内容面からいえば、通常実施権は実施権者が特許発明を独占的に実施することができないのに対して、専用実施権・独占的通常実施権は実施権者が独占的に特許発明を実施することができる。

　このように、権利の内容からいえば専用実施権と独占的通常実施権は類似している。しかし、専用実施権は特許庁に登録がされ、また権利の性質から物権的権利であるといわれるのに対し、独占的通常実施権はあくまで契約関係の中で実施権者に独占的に発明を実施することを許諾したものにすぎない。また、専用実施権においては特許権者自身も特許発明を実施す

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ることはできず、特許発明を実施できるのは専用実施権者のみであるが、独占的通常実施権では契約関係の中で特許権者自身が特許発明を実施することを留保することも可能であるという違いがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　仮専用実施権・仮通常実施権

特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、一定の範囲内において、仮専用実施権を設定し（特許法34条の2）、または他人に仮通常実施権を許諾することができる（特許法34条の3）。

仮専用実施権の設定については、登録しなければその効力を生じない（特許法34条の4第1項）。

仮専用実施権にかかる特許出願について特許権の設定の登録があったときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなされる（特許法34条の2第2項）。仮通常実施権についても同様の定めがある（特許法34条の3第2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ)実施許諾契約(ライセンス契約)

実施許諾契約とは、特許権者が実施権者に対して特許発明について実施を許諾する契約である。

実施許諾契約では、通常次のような事項が規定される。

① 契約当事者の表示
- ・許諾権者(特許権者等)の名称・氏名
- ・実施権者の名称・氏名

② 対象となる特許発明の特定(特許登録番号・発明の名称等)

③ 実施権の態様(専用実施権・通常実施権)

④ 実施権の期間・範囲・制限

⑤ 実施料(額・算定方法、支払方法)

⑥ その他
- ・他の実施権の有無等、当該特許に関する他の権利関係についての事項
- ・秘密保持に関する事項　など

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

実施権設定の対価として、実施料（ロイヤリティ）が支払われる。実施料は、特許権者（ライセンサー）と実施権者（ライセンシー）との間で自由に決められるが、一括で支払う方法や、年度ごとの売上高に係数を掛けて支払う方法等がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　実施許諾契約と独占禁止法

実施許諾契約の締結にあたり、許諾権者（特許権者等）は、その優越した立場を利用し、実施権者に不当な条件を押しつけることがあり、その内容によっては独占禁止法上の「不公正な取引方法」等に該当する可能性がある。

実施許諾契約が独占禁止法に違反するかどうかは、特許権者による権利の行使と認められる行為の範囲（独占禁止法21条）を超えるような内容・条件を含んでいるかどうかが基準となる。例えば、実施権者に実施許諾契約の対象となった特許について争わないことを義務付けることや、特許を実施する製品の販売価格・再販売価格を拘束したり、特許権消滅後も実施権者が当該技術を使用することを制限したりすることは、独占禁止法違反になるおそれがある。これらの点に関し、公正取引委員会は、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」を公表し、知的財産のうち技術に関するものの利用と独占禁止法の適用関係について、一定の考え方を示している。

また、外国から技術を導入する際に結ばれる国際的契約については、契約内容に、不当な取引制限または不公正な取引方法に該当する条件や制約を設けることが制限されている（独占禁止法6条）。なお、国際的な契約については、関係諸外国の独占禁止法の規制を受けることに注意しなければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(10) 特許権の移転

特許権は財産権の一種であり、自由に移転できる。特許権が移転されると、元の特許権者は、当該特許に関する権利をすべて失い、移転を受けた者が特許権者となる。移転の原因には、会社の合併・相続などの一般承継と、売買・贈与などの特定承継がある。

財産権の譲渡には、民法および商法の売買契約に関する規定が適用・準用されるが、特許権の特定承継(売買や贈与など)については、特許登録原簿に登録しなければ特許権移転の効力を生じない(特許法98条1項1号)。一方、一般承継の場合には、登録は効力発生要件ではなく、登録がなくても第三者に権利を対抗できるが、遅滞なく、承継した旨を特許庁長官に届け出なければならない(特許法98条2項)。届出は、特許権者が不明となる状態を防止するためのものであり、登録とは異なる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（特許権の移転）

	効力発生要件	対抗要件	その他
特定承継	承継事由（売買契約等）の成立 ＋ 特許登録原簿への登録（特許法98条1項1号）	－	－
一般承継	承継事由（相続等）の発生	－	特許庁長官への届出（特許法98条2項）

(11)特許権侵害の態様

例えば、特許権等の権原を有しない者が、業として他人の特許発明を実施することは、特許権の侵害になる。特許権者は、特許発明の実施をする権利を専有するからである（特許法68条）。

特許発明は特許請求の範囲における請求項（クレーム）ごとに成立し、特許権侵害もクレームごとに判断する必要がある。そして、あるクレームごとに記載されている発明特定事項（発明の構成）のすべてを具現化した製品を製造・販売する行為等が特許発明の実施行為である。したがって、この実施行為を法的な権原を有しない第三者が行うことが、特許権の直接侵害となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

直接侵害には該当しないが、特許権等の直接侵害を幇助する行為等、直接侵害に密接に関連する一定の行為は、特許権等を侵害するものとみなされている（特許法101条各号）。これらは、一般に、間接侵害や擬制（ぎせい）侵害などと呼ばれている。例えば、特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産や譲渡が間接侵害に当たる（特許法101条1号）。

特許権者は、通常、侵害行為の中止を求める警告書を相手方へ送付するなどの対応をとるほか、以下に述べる方法で侵害に対する措置を講じることができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(12)民事的救済手段

特許権や専用実施権侵害に対する主な民事的救済手段として、次のようなものがある。

① 侵害行為に対する差止請求(特許法100条)
② 仮処分の申立て
③ 侵害によって受けた損害の損害賠償請求(民法709条)
④ 侵害者の不当利得の返還請求(民法703条・704条)
⑤ 業務上の信用が害されたときの信用回復措置の請求(特許法106条)

③の損害賠償請求訴訟については、特許権者等の立証負担を軽減するために、損害額の推定(特許法102条)、過失の推定(特許法103条)の規定が設けられている。

さらに、特許権等の侵害行為に対して、特許権者等が十分な権利行使ができるようにするため、侵害者による侵害行為の具体的態様の明示義務(特許法104条の

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2)、調査のための査証制度(特許法105条の2以下)、広く一般に当該事件に関する特許法の適用等について意見を募集する第三者意見募集制度(特許法105条の2の11)、損害額計算のための鑑定人制度(特許法105条の2の12)、損害額の立証が極めて困難な場合における、裁判所による相当な損害額の認定(特許法105条の3)等が定められている。

(13)刑事責任

特許権を侵害した者は、刑事罰として10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金に処せられることがある(特許法196条)。また、企業活動の一環として特許権の侵害行為を行った場合には、行為者を罰するほか法人に最高3億円の罰金刑が科されることがある(両罰規定:特許法201条)。なお、特許権侵害の罪は、その性質から非親告罪とされている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」

特許法等に基づく権利の行使については、独占禁止法の規定は適用されないが（独占禁止法21条）、一見権利の行使と見られる行為であっても、実質的に見て権利の行使と評価できないこともある。この点に関し、公正取引委員会は、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」を公表している。

この指針では、特許法等（実用新案法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、種苗法、著作権法および意匠法）によって保護される技術等を対象として、これらの技術の利用を制限する行為に対する独占禁止法の適用について、公正取引委員会の考え方が明らかにされている。

一見、特許法等に基づく権利の行使と見られる行為であっても、実質的に見て権利の行使と評価できない場合には、独占禁止法が適用される。この独占禁止法の適用が除外される「権利の行使」と評価できるか否かは、行為の目的、態様、競争に与える影響の大きさを考慮した上で、知的財産制度の趣旨を逸脱する行為等と認められるか否かによって決まる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

《実施許諾契約に対する規制》
次のようなケースは、不当な取引制限ないしは不公正な取引方法に該当し、原則として独占禁止法違反となる。

① 特許対象技術を使用していない製品に実施料を課する。
② 合理的な理由なしに、特許製品の生産に必要な原材料、部品等の購入先をライセンサーが指定する。
③ 特許製品の販売ルートをライセンサーが指定する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の具体的内容

1　競争政策と知的財産制度

知的財産制度は、自由経済体制の下で、事業者に創意工夫を発揮させ、国民経済の発展に資するためのものである。知的財産制度は、その趣旨が尊重されるとともに、円滑な技術取引が行われるようにすることが重要である。

他方、知的財産制度の下で、技術に権利を有する者が、他の事業者がこれを利用することを拒絶したり、利用することを許諾するに当たって許諾先事業者の研究開発活動、生産活動、販売活動その他の事業活動を制限したりする行為（以下「技術の利用に係る制限行為」という。）は、その態様や内容によっては、技術や製品をめぐる競争に悪影響を及ぼす場合がある。

技術の利用に係る制限行為についての独占禁止法の運用については、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」が公表されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　独占禁止法の適用に関する基本的な考え方

(1)権利の行使とはみられない行為

技術の利用に係る制限行為のうち、そもそも権利の行使とはみられない行為には、独占禁止法が適用される(独占禁止法21条反対解釈)。

(2)実質的に権利の行使とは評価できない行為

技術に権利を有する者が、他の者にその技術を利用させないようにする行為および利用できる範囲を限定する行為は、外形上、権利の行使とみられるが、これらの行為についても、実質的に権利の行使とは評価できない場合は、独占禁止法の規定が適用される。

(3)技術の利用に係る制限行為の考え方

原則として、制限行為の影響の及ぶ取引を想定し、その制限行為によって、その取引の行われる市場において競争が減殺されるかどうかを検討する。例えば、制限行為の対象となる技術を使用している事業者の製品シェアの合計が20%以下の場合は、原則として競争減殺効果は軽微であると考えられる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　私的独占または不当な取引制限（独占禁止法3条）の観点からの考え方

（1）私的独占の観点からの検討

技術の利用に係る制限行為が、「他の事業者の事業活動を排除し、又は支配する」（独占禁止法2条5項）ものである場合には、私的独占の規定の適用が問題となる。技術の利用に係る制限行為が「排除」又は「支配」に該当するか否かは、行為の態様により一義的に決まるものでなく、それぞれの行為の目的や効果を個別に検討して判断することになる。

（2）不当な取引制限の観点からの検討

技術の利用に係る制限行為が、「事業者が他の事業者と共同して、相互にその事業活動を拘束しまたは遂行する」（独占禁止法2条6項）ものである場合は、不当な取引制限の規定の適用が問題となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ア）パテントプール

ある技術に権利を有する複数の者が、それぞれが有する権利または当該権利についてライセンスをする権利を一定の企業体や組織体に集中し、当該企業体や組織体を通じてパテントプールの構成員等が必要なライセンスを受けるものを、パテントプールという。

単にパテントプールに該当するというだけでは、不当な取引制限に該当するものではない。

しかし、①一定の技術市場において代替関係にある技術に権利を有する者同士が、それぞれ有する権利について、パテントプールを通じてライセンスをすることとし、その際のライセンス条件について共同で取り決める行為は、②当該技術の取引分野における競争を実質的に制限する場合には、「不当な取引制限」に該当する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ)マルティプルライセンス

マルティプルライセンスは、ある技術を複数の事業者にライセンスをすることをいう。

マルティプルライセンスにおいて、①ライセンサーおよび複数のライセンシーが共通の制限を受けるとの認識の下に、当該技術の利用の範囲、当該技術を用いて製造する製品の販売価格、販売数量、販売先等を制限する行為は、これらの事業者の事業活動の相互拘束にあたり、②当該製品の取引分野における競争を実質的に制限する場合には、「不当な取引制限」に該当する。また、①同様の認識の下に、改良技術について、ライセンスをする相手方、代替技術の採用等を制限する行為も、②技術の取引分野における競争を実質的に制限する場合には、「不当な取引制限」に該当する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ウ)クロスライセンス

技術に権利を有する複数の者が、それぞれの権利を相互にライセンスをすることを、クロスライセンスという。

①事業者が一定の製品市場において占める合算シェアが高い場合に、当該行為の対価、数量、供給先等について共同で取り決める行為や他の事業者へのライセンスを行わないことを共同で取り決める行為は、②当該製品の取引分野における競争を実質的に制限する場合には、「不当な取引制限」に該当する。

技術の利用範囲として、それぞれ当該技術を用いて行う事業活動の範囲を共同して取り決める行為は、技術または製品の取引分野における競争を実質的に制限する場合には不当な取引制限に該当する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　不公正な取引方法(独占禁止法19条)の観点からの考え方

(1)基本的な考え方

ある技術に権利を有する者が、他の事業者に対して当該技術の利用についてライセンスを行わないことや、ライセンスを受けずに当該技術を利用する事業者に対して差止請求訴訟を提起することは、通常は当該権利の行使とみられる行為である。

しかしながら、一定の場合には、権利の行使とは認められないことがある。また、技術の利用範囲を制限する行為や技術の利用に関し制限を課す行為は、外形上、権利の行使とみられるが、実質的に権利の行使と評価できない場合がある。

本指針では、技術の利用に係る制限行為が、不公正な取引方法(独占禁止法19条)との関係で問題となる場合につき、①技術を利用させないようにする行為、②技術の利用範囲を制限する行為、③技術の利用に関し制限を課す行為、④その他の制限を課す行為に分けて述べられている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)「②技術の利用範囲を制限する行為」の考え方の例

ア)製造できる地域の制限

ライセンサーがライセンシーに対し、当該技術を利用して製造を行うことができる地域を限定する行為は、一般には権利の行使と認められるものであり、原則として不公正な取引方法に該当しない。

イ)製造数量の制限または製造における技術の使用回数の制限

ライセンサーがライセンシーに対し、当該技術を利用して製造する製品の最低製造数量または技術の最低使用回数を制限することは、他の技術の利用を排除することにならない限り、原則として不公正な取引方法に該当しない。

他方、製造数量または使用回数の上限を定めることは、市場全体の供給量を制限する効果がある場合には権利の行使とは認められず、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する(一般指定第12項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

5　実用新案権〔utility model right〕

(1) 実用新案権とは

実用新案権は、業として実用新案を実施する権利である(実用新案法16条)。特許法が比較的高度な発明を保護して飛躍的な産業の発達を図ることを目的とする法律であるの対して、実用新案法は物品に具現されている考案(発明ほど高度でない技術的創作)を保護する。特許法で保護される発明の水準を維持しつつも、小発明を積極的に保護するところに、実用新案法の存在意義がある。

(2) 実用新案権の対象

実用新案登録の対象は、物品の形状、構造、組合せにかかる考案である。考案は、自然法則を利用した技術的思想の創作であり、高度な創作に限られない点が特許発明と異なるのに加え、実用新案権が付与されるのは、考案の中でも物品の形状、構造または組合せにかかるものに限られる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

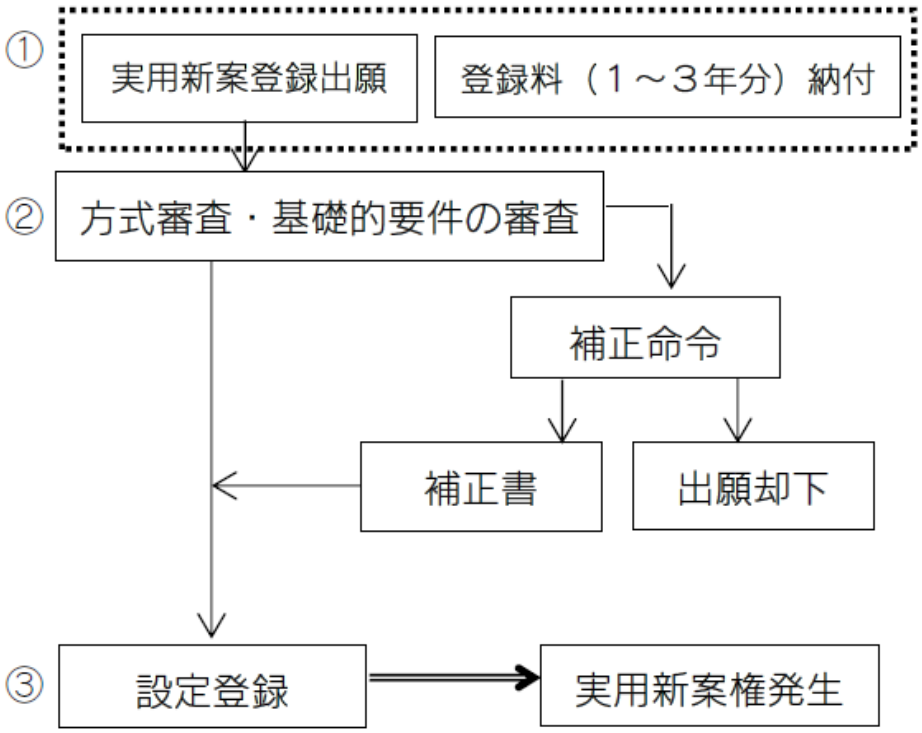
(3) 実用新案権の取得手続

実用新案については、出願の後、形式的審査(方式審査)のみによって実用新案権の設定登録を行う早期登録制度(無審査登録制度)がとられている(実用新案法14条2項)。すなわち、実用新案登録出願があったときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、または却下された場合を除き、実用新案権の設定登録がなされる。小発明は出願後極めて短期間で実施されるのが通常であり、この制度により早期に権利行使が可能となる。

また、出願の日から3年以内であれば、実用新案登録出願を特許出願に変更することができ(特許法46条)、実用新案登録後であっても、原則として、実用新案登録に基づいて特許出願を行うことができる(特許法46条の2)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（実用新案権の取得手続の流れ）



①実用新案登録を受けようとする者は、所定の書類を特許庁長官に提出して、実用新案登録出願をしなければならない。
また、実用新案登録出願をするときには、第1年から第3年分の登録料を納付する必要がある。

②方式審査は、なされた出願の形式面を審査するものである。
また併せて、出願が物品の形　状、構造、組合せにかかる考案であることなどの基礎的要件が審査される。

③方式上の要件および基礎的要件を充たす場合、新規性等の実体審査を経ずに設定登録がなされる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

実用新案については、実体的登録要件を審査せず、方式審査および基礎的要件の審査のみで実用新案権の設定登録がなされる。そのため、実質的に保護レベルに達していない実用新案が登録され、権利行使がなされるおそれがある。そこで、このような権利の濫用を防止するため、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、侵害者に対して実用新案権を行使することができない（実用新案法29条の2）。また、実用新案権者等が侵害者に対して実用新案権を行使した後に、その実用新案登録の無効審決が確定したときは、原則として権利行使をした実用新案権者が損害賠償責任を負う（実用新案法29条の3）。

（4）実用新案権の効力

実用新案権は、設定登録により発生する（実用新案法14条1項）。

実用新案権の存続期間は出願日から10年である（実用新案法15条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

6　営業秘密〔trade secret〕

営業秘密とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」をいう（不正競争防止法2条6項）。いわゆるノウハウが含まれ、商品の製造方法、設計図・実験データ等の技術情報、顧客リストや販売マニュアル等の営業情報などが営業秘密に当たる。営業秘密には、①特許権・実用新案権の対象とならない営業情報、②新規性・進歩性があるかどうかにかかわらず社外秘としておきたい重要な技術情報、③権利取得のために時間をかけられない情報などが含まれる。

営業秘密は、登録等により国から独占排他権を得ることで保護されるわけではないため、物権的権利とはいえないが、法的に保護すべき利益であり、知的財産の一種として、不正競争防止法や民法等による保護の対象となっている（第3章第3節2～4、第5章第2節参照）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　知的財産取引に関するガイドライン

知的財産における取引の問題事例の防止や知的財産取引における企業間の共存共栄を図るため、中小企業庁によって、「知的財産取引に関するガイドライン」が作成されている。「知的財産取引に関するガイドライン」では、知的財産がかかわる取引における基本的な考え方と参考事例が、「あるべき姿」および「問題事例」として示されている。

1　契約締結前

(1)あるべき姿

秘密情報を、相手方の事前の承諾を得ることなく、取得して、または開示を強要してはならない。相手方の秘密情報を知った場合には、これを厳に秘密に保持するものとし、相手方から事前に明示的に承諾を得ることなく利用し、または、第三者へ開示してはならない。

当事者の意思に反するような形で事前に秘密保持契約を締結することなく、取引交渉や工場見学等、相手方のノウハウや技術上または営業上の秘密等を知り得る行為をしてはならない。この場合において、一方当事者のみが秘密保持条項を負う内容のものであってはならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)問題事例

　A社は、B社からA社への工場見学を検討している旨連絡を受けたが、A社が何度依頼してもB社は秘密保持契約に応じてくれない。

2　試作品製造・共同開発等

(1)あるべき姿

　競合する取引先への技術指導、試作品の製造や技術指導、実験等を意に沿わない形で強制してはならない。

　また、試作品等の製造を依頼する場合には、実費(材料費、人件費等)は当然のこととして、技術に対する対価、利益を含む適切な対価を支払わなければならない。

(2)問題事例

　A社はB社より製造委託を受けていたが、ある時からB社はC社に発注先を変更した。しかし、C社がうまく製造できないことを理由に、A社からC社に技術指導を無償で実施するように強制された。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　製造委託・委託販売・請負販売等

(1)あるべき姿

製造委託にあたり、委託本来の目的に照らして合理的に必要と考えられる範囲を超えて、相手方の有するノウハウ、アイディア、レシピ等の技術上または営業上の秘密情報、または技術指導等の役務（以下、総称して「技術情報等」という。）の提供を求めてはならない。

(2)問題事例

A社はB社から製造委託を受託したところ、B社より定期的かつ詳細な報告が求められたほか、製造現場を動画で撮影されることで、A社のノウハウをはじめとする技術情報等がB社に吸い上げられてしまった。

4　特許出願・知的財産権の無償譲渡・無償実施許諾

(1)あるべき姿

取引とは直接関係のないまたは中小企業が独自に開発した発明その他これに係る独自の改良発明等の出願、登録等について、事前報告や出願等の内容の修正を求めるなど、企業が単独で行うべき出願等に干渉してはならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

相手方が生み出した特許権等について、相手方に対し、無償による譲渡を強要したり、相当の対価を支払うことなく自社に単独帰属することを強要してはならない。また、相手方が生み出した特許権等の知的財産権について、自社が相手方に対し、相当の対価を支払うことなく相手方または第三者への実施許諾を強制してはならない。

(2)問題事例

A社はB社に納品後に、取引の中で生じた技術に関わる権利をすべてB社に帰属するような契約を締結させられた。

5　第三者との間に生じる知財訴訟等のリスクの転嫁

(1)あるべき姿

発注者の指示に基づく業務について、第三者との間に生じる知的財産上の責任や負担を、受注者に例外なく一方的に転嫁し、またはその旨を契約に定めてはならない。

(2)問題事例

A社は、B社からの指示に基づく業務にもかかわらず、知財財産権に関する訴訟等が生じた場合、A社はその責任を負うという契約条件を押しつけられた。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD